

1500979-02.2021.8.26.0599

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Flavia de Cassia Gonzales de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/03/2022

... PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO (FECHADO). VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL (CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME). PRESENÇA DE DUAS QUALIFICADORAS DO DELITO. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS QUALIFICADORAS PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. 1. Embora estabelecida a pena definitiva menor que 8 anos (5 anos e 4 meses de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

2ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Sala 05/07, Alemães - CEP 13417-100, Fone: (19)3433-4177, Piracicaba-SP - E-mail: piracicaba2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1500979-02.2021.8.26.0599

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (Crime Tentado)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2169096/2021 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 18650705 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO,

1715/21/922 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 2169096 - 02º D.P. PIRACICABA,

1715/21/922 - 02º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDUARDO HENRIQUE DOS SANTOS

Vítima:

ESCOLA MUNICIPAL HIDE MALUF JUNIOR

Artigo da Denúncia:

*

Tramitação prioritária

Aos 08 dias do mês de março de 2022, à hora designada, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG 284/2020, apresentaram-se a Exma. Sra. Dra. FLAVIA DE CASSIA GONZALES DE OLIVEIRA, MMª Juíza de Direito, o representante do Ministério Público, Dr.Rafael Augusto Pressuto e o(a) Defensor(a) Público(a), Dr(a).Daniela Batalha Trettel. Apresentados o(a)(s) acusado(a)(s) EDUARDO HENRIQUE DOS SANTOS e as testemunhas arroladas em comum pelas partes André da Silva Pazetti, Valdemir de Oliveira Machado, e Marise do Amaral Campos Cillo. Ausente o acusado Eduardo Henrique dos Santos o qual, ao ser intimado (fls.143), informou que não tinha condições de participar virtualmente da audiência e foi orientado a comparecer ao fórum, mas não o fez. INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes, pela MM. Juíza foi(ram)

colhido(s) o(s) depoimento(s) da(s) testemunha(s) (Valdemir, André e Marise) pelo sistema virtual.

Em seguida, pela MM Juíza foi deliberado:

Tendo em vista que o réu deveria comparecer ao fórum para participar da audiência mas não o fez, DECRETO A SUA REVELIA.

“Não havendo mais provas a serem produzidas, encerro a instrução, determinando às partes que passem aos debates orais:

Dada a palavra ao(à) ilustre representante do Ministério Público, manifestou-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM. Juíza,

EDUARDO HENRIQUE DOS SANTOS foi denunciado como incurso no artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I e II, c.c. o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, pois, no dia 23 de junho de 2021, por volta de 02h40min, nas dependências da “Escola Municipal Hide Maluf Junior”, situada na Rua Bom Pastor, n.º 282, Vila Cristina, nesta cidade e Comarca de Piracicaba, durante o período de repouso noturno, tentou subtrair, para si ou para outrem, mediante escalada e rompimento de obstáculo, 01 (um) aparelho televisor 31” da marca Buster, avaliado em R\$500,00 (quinhentos reais), e 02 (dois) maços de hastes em alumínio, avaliados em R\$200,00 (duzentos reais), pertencentes à “Escola Municipal Hide Maluf Junior”, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

O processo teve andamento regular.

A denúncia foi recebida a fls. 106/107. Devidamente citado a fls. 114, o réu apresentou resposta à acusação a fls. 118/119. Durante a instrução, o réu foi interrogado e foram ouvidas as testemunhas arroladas.

É a síntese do necessário.

No mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade delitiva veio comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão de fls. 21, laudo pericial de fls. 131/138, bem como pelas provas colhidas em juízo.

Autoria por parte do acusado também restou devidamente comprovada.

Com efeito, o policial militar Andre Da Silva Pazetti, na Delegacia de Polícia, relatou: “estava em patrulhamento de rotina pelo Bairro Vila Cristiana, por volta das 03:30 horas, quando foram solicitadas via COPOM, dando conta de um furto em andamento junto a uma Escola Municipal por nome de Hide Maluf Junior, que fica na Rua Presidente Venceslau Braz. Diante da informação os policiais de imediato foram até o local, e quando chegaram, ouviram ruídos e barulhos de dentro da escola. Os policiais constaram que um portão da quadra esta arrombado, e adentram na escola. Informa o policial que conseguiram flagrar um indivíduo que estava dobrando barras de alumínio, possivelmente da cerca de concertina. Os policiais abordaram o indivíduo, sendo que este foi identificado depois, por EDUARDO HENRIQUE DOS SANTOS. Os policiais ainda localizaram uma TV, que também tinha sido furtada, que estava na parte externa da escola. Esclarece o policial que EDUARDO, para ter acesso ao interior da escola, além de arrombar o portão, também escalou vários muros altos. Foi localizado na posse de EDUARDO um saco de várias hastes de alumínio, além da TV, sendo estes objetos avaliados em aproximadamente R\$700,00 reais. Esclarece o policial que não foram localizados nesta madrugada os representantes da escola. Assim foi utilizado algemas visando resguardar a integridade da equipe policial bem como do acusado e evitar fugas. Assim, tendo em vista os fatos o policial deu voz de prisão em flagrante e o encaminhou a esta Delegacia de Polícia para que fossem tomadas as medidas cabíveis de Polícia Judiciária” (fls. 07).

Em juízo, o policial confirmou os fatos narrados na fase informativa. Disse que foram acionados por uma vizinha, dando conta do furto na escola. Na ocasião, encontraram o acusado, no interior da escola, enrolando hastes de alumínio do para-raios do estabelecimento. Informou que, para subtrair os bens, o acusado arrombou uma porta e escalou muros para pegar as hastes metálicas. Ademais, o acusado já havia separado uma televisão para a subtração, que havia sido subtraída de um pavilhão de salas de aula, cuja porta estava danificada e sem o aparelho televisor. O réu, na oportunidade, confessou a prática do furto, mas negou o arrombamento. Esclareceu que o televisor estava fora da área construída da escola, próximo ao

portão de saída, separada para a subtração, sendo que apenas conseguiram localizar o bem com a utilização de lanternas.

O policial militar Valdemir de Oliveira Machado, ouvido em solo policial, relatou: "estava em patrulhamento de rotina pelo Bairro Vila Cristiana, por volta das 03:30 horas, quando foram solicitadas via COPOM, dando conta de um furto em andamento junto a uma Escola Municipal por nome de Hide Maluf Junior, que fica na Rua Presidente Venceslau Braz. Diante da informação os policiais de imediato foram até o local, e quando chegaram, ouviram ruídos e barulhos de dentro da escola. Os policiais constaram que um portão da quadra esta arrombado, e adentram na escola. Informa o policial que conseguiram flagrar um indivíduo que estava dobrando barras de alumínio, possivelmente da cerca de concertina. Os policiais abordaram o indivíduo, sendo que este foi identificado depois, por EDUARDO HENRIQUE DOS SANTOS. Os policiais ainda localizaram uma TV, que também tinha sido furtada, que estava na parte externa da escola. Esclarece o policial que EDUARDO, para ter acesso ao interior da escola, além de arrombar o portão, também escalou vários muros altos. Foi localizado na posse de EDUARDO um saco com várias hastes de alumínio, além da TV, sendo estes objetos avaliados em aproximadamente R\$ 700,00 reais. Esclarece o policial que não foram localizados nesta madrugada os representantes da escola. Assim foi utilizado algemas visando resguardar a integridade da equipe policial bem como do acusado e evitar fugas. Assim, tendo em vista os fatos o policial deu voz de prisão em flagrante e o encaminhou a esta Delegacia de Polícia para que fossem tomadas as medidas cabíveis de Polícia Judiciária" (fls. 05/06).

Em juízo, o policial confirmou os fatos narrados na fase administrativa. Relatou que foram acionados a comparecer ao local, em razão da prática de um furto, quando encontraram o acusado no interior da escola. O réu já havia separado uma televisão e manuseava objetos de alumínio. O acusado havia escondido o televisor próximo de uma árvore, do lado externo da escola. Informou que a porta da sala de aula estava arrombada. O acusado confessou que havia separado a televisão para posterior subtração. Para ingressar na escola, o acusado escalou um muro, quebrou offendículos que havia no local, arrombou uma das portas das salas. Disse, ainda, que os fatos ocorreram durante a madrugada.

Marise do Amaral Campos Cillo, indicada como representante da escola, relatou, em juízo, que, na verdade, não trabalha na escola em questão, sendo provável que tenha ocorrido algum mal atendido, até porque trabalha em escola estadual, mas a escola situada no local dos fatos é municipal.

Interrogado em sede policial, o réu exerceu seu direito de permanecer em silêncio quantos aos fatos (fls. 08/09).

Em juízo, o acusado não compareceu para o interrogatório, sendo decretada a revelia.

Vale ressaltar, por oportuno, que os depoimentos prestados pelos policiais militares são plenamente válidos como meio de prova, se produzidos sob o crivo do contraditório e se estiverem coerentes com as demais provas produzidas, como ocorre no caso em tela.

Nesse sentido já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça, nos termos do voto do Ministro Arnaldo Esteves Lima, no julgamento do HC nº 123293/MS, publicado no dia 16/11/2009, do qual se extrai o seguinte trecho: "O depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de prova". Ainda nesse sentido: "PROVA - TESTEMUNHA - Depoimento de agentes policiais - Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas - Análise que se faz em cada caso concreto - Inexistência de dúvida que justifica o decreto condenatório - O testemunho de policiais, que no cumprimento de sua missão atuam na repressão penal, é tão válido como de qualquer outro testemunho - Merecem credibilidade e se de acordo ou conformidade com as demais provas, justificam um decreto condenatório - Entendimento - Precedentes - Recurso parcialmente provido" (Apelação n. 990.08.180251-1 - Birigui - 16ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Newton de Oliveira Neves - 04/05/2010 - 8640 - Unânime). (Grifei).

Pequenas divergências com relação a elementos secundários da prova são naturais, ante as inúmeras ocorrências a que os policiais estão submetidos a atender. Demais disso, o painel probatório confirma as qualificadoras da escalada e do rompimento do obstáculo, bem como a circunstância do repouso noturno, conforme relatado pelo representante da vítima e testemunhas. Destarte, tem-se que o crime descrito na denúncia restou bem comprovado, sendo a condenação de rigor.

No que tange à dosimetria da pena, observo que o acusado é primário, mas foi preso em flagrante delito após os fatos tratados neste processo, o que deve ser considerado como circunstância judicial desfavorável.

Anoto, ainda, que o acusado foi beneficiado, no curso deste processo, com a liberdade provisória, mediante os compromissos de comparecimento a todos os atos do processo e de não mudar de residência sem a devida comunicação ao juízo, mas, mesmo assim, traiu a confiança do juízo e tornou-se revel. Ademais, como dito, tornou a delinquir. Tais circunstâncias devem ser consideradas como circunstância judicial desfavorável.

Ademais, não há dúvidas de que o furto cometido com mais de uma qualificadora deve ser apenado de forma mais rigorosa que aquele cometido com apenas uma, justamente porque se trata de fato mais grave. Se assim não fosse, o agente mais perverso com sua conduta duplamente qualificada seria premiado com pena semelhante àquele que realiza uma qualificadora do furto. Haveria nítida afronta ao princípio da individualização da pena, postulado de fundo constitucional (art. 5º, XLVI, da CF/88).

É com base nesse primado que se admite, nas hipóteses de pluralidade de qualificadoras do mesmo tipo penal, a utilização de uma delas para qualificar o crime e as demais ou i) para a exasperação da pena-base ou para ii) agravá-la na segunda fase da dosimetria, caso incluída no rol do art. 61, II, do CP.

Não há como desconsiderar que a incidência de várias qualificadoras torna a conduta mais reprovável, atraindo uma resposta penal mais enérgica. Nessa senda, inadmissível seria um mesmo tratamento ao agente que pratica um furto unqualificado e àquele que pratica o mesmo delito biqualeficado.

No ponto:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO (FECHADO). VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL (CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME). PRESENÇA DE DUAS QUALIFICADORAS DO DELITO. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS QUALIFICADORAS PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. 1. Embora estabelecida a pena definitiva menor que 8 anos (5 anos e 4 meses de reclusão), a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em razão da existência de circunstância judicial negativa (circunstâncias do crime: o fato se deu mediante concurso de agentes), o que justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado. 2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, havendo mais de uma qualificadora no furto, uma delas pode formar o tipo qualificado e as demais podem ser utilizadas para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria (caso conste no rol do art. 61, II, do CP) ou para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo, como feito no presente caso. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1630537/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017).

Do exposto, na hipótese de pluralidade de qualificadoras, não há ilegalidade na utilização de uma para qualificar o crime e as demais sobejantes para a exasperação da pena-base (art. 59, CP) ou para agravar a pena na segunda fase da dosimetria, quando constante do rol do art. 61, do CP. Mormente porque devidamente fundamentada a aplicação da pena, o entendimento alinha-se perfeitamente com ao princípio da individualização da pena.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Já na terceira fase de dosimetria da pena, incide a causa de aumento de 1/3 (um terço) referente ao repouso noturno, estampada no § 1º do art. 155, do CP.

Considerando que o crime foi tentado, entendo que a reprimenda deva ser reduzida em 1/3, considerando o iter criminis percorrido, uma vez que os bens já estavam separados do lado externo da escola.

Outrossim, a quantidade da pena a ser fixada, bem como a as circunstâncias judiciais desfavoráveis impõem a fixação inicial do regime semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "b", e § 3º, do Código Penal, vedada a substituição da pena corporal por restritiva de direitos ou "sursis".

Ante o exposto, aguardo a procedência da denúncia, com a condenação do réu EDUARDO HENRIQUE DOS SANTOS nos moldes pleiteados.

Dada a palavra ao(à) nobre defensor(a) do(a)(s) acusado(a)(s), manifestando-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM.Juíza, Eduardo Henrique dos Santos foi denunciado como incurso no artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I e II, c. c/ artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Segundo a denúncia (fls. 101-102), no dia 23 de junho de 2021, por volta de 02h40min, nas dependências da "Escola Municipal Hide Maluf Junior", situada na rua Bom Pastor, n.º 282, Vila Cristina, nesta cidade e comarca de Piracicaba/SP, Eduardo, durante o período de repouso noturno, tentou subtrair, para si ou para outrem, mediante escalada e rompimento de obstáculo, 01 (um) aparelho televisor 31" da marca Buster, avaliado em R\$500,00 (quinhentos reais), e 02 (dois) maços de hastes em alumínio, avaliados em R\$200,00 (duzentos reais), pertencentes à escola, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Ainda de acordo com a inicial, aproveitando-se da vigilância atenuada pelo período de repouso noturno, Eduardo se dirigiu ao estabelecimento escolar para a prática de furto. Após escalar o muro da escola e arrombar o portão de uma quadra, ingressou no imóvel e passou a se apoderar dos objetos acima descritos. Ocorre que, no momento que extraia hastes de alumínio fixadas no imóvel, foi detido por policiais militares acionados ao local – o televisor já estava separado na parte externa (auto de fls. 21 e foto fls. 34). O crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu, quais sejam, a comunicação anônima à Polícia Militar e a pronta intervenção dos agentes policiais.

Interrogado na Delegacia de Polícia, o réu exerceu o direito constitucional ao silêncio (fls. 8-9).

Valdemir de Oliveira Machado, policial militar, narrou que: "estava em patrulhamento de rotina pelo Bairro Vila Cristiana, por volta das 03h30, quando foram solicitados via COPOM, para averiguar um furto em andamento junto a uma Escola Municipal por nome de Hide Maluf Junior, que fica na rua Presidente Venceslau Braz. Diante da informação, de imediato, foram até o local, e quando chegaram, ouviram ruídos e barulhos de dentro da escola. Constaram que um portão da quadra estava arrombado, e adentram na escola. Conseguiram flagrar um indivíduo que estava dobrando barras de alumínio, possivelmente da cerca de concertina. Abordaram o indivíduo, sendo que este foi identificado depois, por Eduardo Henrique dos Santos. Localizaram ainda uma TV, que também tinha sido furtada, que estava na parte externa da escola. Para Eduardo ter acesso ao interior da escola, além de arrombar o portão, ele também escalou vários muros altos. Foi localizado na posse de Eduardo um saco com várias hastes de alumínio, além da TV, sendo estes objetos avaliados em aproximadamente R\$ 700,00 reais. Não foram localizados nesta madrugada os representantes da escola" (fls. 5-6).

No mesmo sentido a versão apresentada pelo policial militar André da Silva Pazetti (fls. 7).

Às fls. 39, certidão de objeto e pé que indica a primariedade do requerido.

- DA PRODUÇÃO DE PROVAS NOS AUTOS

A materialidade do delito se comprova pelos autos de exibição e apreensão de fls. 21, fotografia de fls. 34 e laudo de exame do local dos fatos de fls. 131-138

("[...] duas portas no interior da escola encontravam-se obstruídas com orientação dos danos de fora para dentro, compatíveis com arrombamento" e "o provável meio de acesso ao interior da escola deu-se por escalada e obstrução/rompimento de obstáculo").

Com relação à autoria, em audiência de instrução foram colhidos os seguintes elementos:

a) Inicialmente, foi ouvida Marise do Amaral Campos Cillo, diretora escolar/representante. Informou que não trabalha na escola vítima do furto. A escola é municipal, e a depoente trabalha na rede estadual.

b) Na sequência, ouvido o policial militar André da Silva Pazetti. Relatou que foram acionados via COPOM para atender a denúncia da vizinha da escola vítima, que relatou ouvir barulhos no local. Ali chegando, viram o réu enrolando as hastes do para-raios no interior da escola, abaixado em um canto. O local também tinha portas arrombadas. A escola é grande, um quarteirão inteiro. Rodearam o local e viram um portão aberto, que dava acesso à quadra da escola. Para retirar o para-raios, o réu teve que escalar muro, pois o equipamento fica sobre o telhado. Havia também uma TV separada pelo réu. O local onde ela estava instalada estava arrombado e com fios puxados. Eduardo confessou o furto do para-raios, mas não disse que danificou a escola para retirar a TV. Sobre o portão aberto, estava sem cadeado, não havia sinais de arrombamento. A porta arrombada era uma porta interna. A TV estava fora da sala de aula, mas ainda no pátio do colégio.

c) Em seguida, foi ouvido Valdemir de Oliveira Machado, policial militar. Relatou que o réu tinha separado um aparelho de televisão e hastes de alumínio (ofendículos). O indivíduo foi preso dentro da escola. A TV estava na parte de fora da escola, escondida atrás de uma árvore, mas o réu tinha retornado ao estabelecimento para buscar as hastes de alumínio. O réu confessou que havia pegado também a TV. O réu ingressou na escola escalando o muro, quebrou ofendículos, arrombou uma das portas das salas para retirar a TV. Não conhecia o réu, mas o outro policial, André Pazetti, já o conhecia. Não se recorda o horário da ocorrência, mas era na madrugada.

d) Por fim, o réu Eduardo Henrique dos Santos é revel.

- DA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INSIGNIFICÂNCIA DA CONDUTA

Tendo em vista que os bens subtraídos foram restituídos à representante da escola, o caso é de absolvição por atipicidade material da conduta, em virtude do reconhecimento do princípio da insignificância.

Nesse contexto, de início, saliente-se que insignificância é uma causa de exclusão da tipicidade, como afirma, a propósito, Paulo Queiroz:

"O princípio da insignificância constitui, portanto, um instrumento por cujo meio o juiz, em razão da manifesta desproporção entre crime e castigo, reconhece o caráter não criminoso de um fato que, embora formalmente típico, não constitui uma lesão digna de proteção penal, por não traduzir uma violação realmente importante ao bem jurídico tutelado" (Direito penal: parte geral, v. 1. 13. ed. Salvador: Juspodivm, 2018, p. 91).

Dinamizando a incidência da insignificância, o Supremo Tribunal Federal, fixou o entendimento sobre a necessidade da verificação de quatro pressupostos para sua aplicação: a) a pequena ofensividade da conduta do agente; b) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; c) nenhuma periculosidade social da ação; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada:

"E M E N T A: PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES CUJA PRESENÇA LEGÍTIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO DE POLÍTICA CRIMINAL - CONSEQUENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL - DELITO DE FURTO - CONDENAÇÃO IMPOSTA A JOVEM DESEMPREGADO, COM APENAS 19 ANOS DE IDADE - "RES FURTIVA" NO VALOR DE R\$ 25,00 (EQUIVALENTE A 9,61% DO SALÁRIO MÍNIMO ATUALMENTE EM VIGOR) - DOUTRINA - CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF - PEDIDO DEFERIDO. O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUALIFICA-SE COMO FATOR DE DESCARACTERIZAÇÃO MATERIAL DA TIPICIDADE PENAL. - O princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. Doutrina. Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público. O POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA E A FUNÇÃO DO DIREITO PENAL: "DE MINIMIS, NON CURAT PRAETOR". - O sistema jurídico há de considerar a relevantíssima

circunstância de que a privação da liberdade e a restrição de direitos do indivíduo somente se justificam quando estritamente necessárias à própria proteção das pessoas, da sociedade e de outros bens jurídicos que lhes sejam essenciais, notadamente naqueles casos em que os valores penalmente tutelados se exponham a dano, efetivo ou potencial, impregnado de significativa lesividade. O direito penal não se deve ocupar de condutas que produzam resultado, cujo desvalor - por não importar em lesão significativa a bens jurídicos relevantes - não represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social." (HC 84412, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, j. em 19/10/2004).

Este julgado tornou-se o verdadeiro leading case da matéria e vem sendo reiterado por inúmeras decisões, tanto do próprio Supremo Tribunal Federal, quanto deste Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, a título exemplificativo, citam-se os seguintes precedentes: a) no STF: HC 97129/RS, Min. Rel. Eros Grau; HC 97189/RS, Min. Rel. Ellen Gracie; STF, HC 96496/MT, Min. Rel. Eros Grau; HC 105974, Min. Rel. Ayres Britto; HC 93393, Min. Rel. Cézar Peluso; HC 93453, Min. Rel. Joaquim Barbosa; b) no STJ, RHC 23.376/MG, Min. Rel. Napoleão Nunes Maia Filho; HC 198996/SC, Min. Rel. OG Fernandes; HC 34626/MG, Min. Rel. Félix Fischer; STJ, HC 18314/RJ; HC 139015/SP, Min. Rel. OG Fernandes; HC 122435/MG, Min. Rel. Celso Limongi.

Ora, a aplicação do princípio da insignificância é uma questão de política criminal, afastando a intervenção penal para delitos que, do ponto de vista jurídico-penal, são considerados menos reprováveis. E, ao fazê-lo, permite-se que o poder punitivo seja exercido de forma mais enérgica em relação aos delitos que, efetivamente, atentam contra a paz social.

Saliente-se, ainda, que o reconhecimento da insignificância não irá causar qualquer desamparo à vítima. Pelo contrário, o que se postula é que seja reconhecida a insignificância do ponto de vista jurídico-penal. Ou seja, o que se requer é o afastamento das consequências jurídico-penais. Com isso, a vítima, caso entenda que tenha sofrido algum tipo de prejuízo, ainda poderá pleitear a devida reparação na esfera civil, eis que a sentença que reconhece a atipicidade da conduta não produz coisa julgada na esfera extrapenal (CPP, art. 67, III). Percebe-se, dessa forma, que somente se justificaria manter a persecução penal para assegurar à vítima um título executivo judicial, eis que a sentença penal condenatória torna certa a obrigação de indenizar (CP, art. 91 c. c/ CPC, art. 515, VI). Todavia, é necessário separar as esferas penal e civil e, assim, retiradas as consequências jurídico-penais da conduta, não se justifica a manutenção do processo penal, seja por causa dos inúmeros gravames que serão causados ao imputado, seja pelo fato que os interesses da vítima - meramente econômicos - ainda estarão amparados pelo ordenamento.

Se é assim, impõe-se a absolvição, na forma do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

- DA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS

No mais, ainda que se entenda tipicidade da conduta, é o caso de absolvição por insuficiência probatória. Como as provas produzidas no presente feito não foram aptas a demonstrar, de forma cabal, a caracterização do crime imputado, tem-se que a prolação de um decreto absolutório é a única medida adequada ao caso, para que se respeite o princípio basilar do in dubio pro reo, tudo nos termos do artigo 386, inciso VII, Código de Processo Penal.

- DA FIXAÇÃO DA PENA

Subsidiariamente, na remota possibilidade de condenação, passa-se a discorrer sobre a pena.

a) Da pena-base

De rigor a fixação da pena-base em seu mínimo legal, pois não há circunstâncias judiciais desfavoráveis.

b) Da segunda fase da dosimetria

Na segunda fase, a circunstância atenuante da menoridade deve ser reconhecida, ainda que a pena não sofra alteração.

c) Da tentativa

Na terceira etapa de dosimetria de pena, conforme se infere dos elementos de prova produzidos em juízo, o acusado esteve muito distante da consumação: logo após dar início à subtração, ele foi surpreendido pelos policiais que impediram a consumação do delito.

Assim, a minorante do art. 14, II, do Código Penal deve ser aplicada em seu patamar máximo.

d) Do repouso noturno

Na terceira etapa de dosimetria de pena, é de rigor o afastamento da majorante do repouso noturno (CP, art. 155, § 1º).

Isso porque, conforme se infere da redação do § 1º do art. 155 do Código Penal, é imprescindível a perturbação do repouso noturno, o que não se pode considerar ter ocorrido, tendo em vista que a suposta subtração se deu em estabelecimento escolar que se encontrava fechado.

É o que entende a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo:

“Não obstante, deve ser afastada a causa de aumento prevista no §1º do artigo 155 do Código Penal (crime praticado durante o repouso noturno), pois para que seja configurada esta causa, não basta que o furto ocorra no período noturno, mas que a vítima se encontre em repouso no local furtado, o que não ocorreu no caso presente, pois o veículo estava estacionado na via pública. Nesse sentido:

'Predomina em nossos pretórios o entendimento de que a agravante especial de furto noturno só pode ser reconhecida quando a ação ocorre em casa habitada, cujos moradores estejam repousando. Incabível tal reconhecimento por ter sido cometido contra estabelecimento comercial' (TACRIM-SP AC Rel. MafraCarbonieri RJD 6/97); 'Impõe-se, no entanto, a exclusão da majorante do furto noturno, pois demonstrado nos autos que a ação ocorreu na via pública, não se podendo cogitar, portanto, de 'repouso noturno', como exige o dispositivo. Nesse sentido, já se decidiu que, 'para que se caracterize a qualificadora do repouso noturno, é necessário que o furto seja perpetrado em casa habitada, cujos moradores estejam dormindo' (RJD 25/191, rel. Junqueira Sangirardi), bem como que 'para o reconhecimento da agravante do art. 155, § 1º, do CP, é necessário que o furto seja praticado em casa habitada, onde haja alguém repousando. Deste modo, o furto de veículo em via pública não enseja a aplicação da majorante do furto noturno' (RT596/410)' (Apelação Criminal nº 0079341-95.2018.8.26.0050, Rel. Des. Vico Mañas, j. em 03.04.2019)". (Apelação criminal 1500872-89.2020.8.26.0599, Rel. Des. Heitor Donizete de Oliveira, j. em 08.02.2022)

Sendo assim, mostra-se de rigor o afastamento da majorante do art. 155, § 1º, do Código Penal, eis que não ocorreu a “perturbação do repouso noturno”.

- DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

No que tange ao regime inicial, em atenção ao disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, diante da quantidade pena a ser aplicada e das circunstanciais judiciais, inexistindo fundamentação concreta a recomendar o regime mais gravoso (Súmulas 718 e 719 do STF; Súmula 440 do STJ), de rigor a aplicação do regime aberto.

- DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA (FURTO PRIVILEGIADO)

Considerando que o requerido primário e o valor das coisas furtadas é baixo, requer-se, nos termos do art. 155, §2º, do CP, a substituição da pena de reclusão pela de multa. Subsidiariamente, requer-se a substituição da reclusão pela detenção com a diminuição máximo de 2/3.

Ressalta-se que, mesmo sendo reconhecida a qualificadora do furto, a jurisprudência assentada é a de que “é possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva” (Súmula 511 do STJ).

- DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS

No mais, aplicável ao caso, o disposto no artigo 44 do Código Penal: o crime não foi cometido mediante violência ou grave ameaça, a pena aplicável ao caso não supera 4 anos, o réu é primário e suas condições pessoais autorizam a substituição.

- DO RECURSO EM LIBERDADE

Considerando que o requerido respondeu ao presente processo em liberdade, não praticou crime com violência ou grave ameaça e não representa perigo à segurança da

sociedade, requer-se que lhe seja concedido o direito de recorrer em liberdade.

Em seguida pelo(a) MM.Juiz(a) foi dito o seguinte:

Passo a proferir a seguinte sentença:

VISTOS.

EDUARDO HENRIQUE DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 155, parágrafos 1º e 4º, incisos I e III, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque no dia 23 de junho de 2021, por volta de 02h40, nas dependências da "Escola Municipal Hide Maluf Junior", situada na Rua Bom Pastor, n.º 282, Vila Cristina, nesta cidade e Comarca de Piracicaba, durante o período de repouso noturno, tentou subtrair, para si ou para outrem, mediante escalada e rompimento de obstáculo (laudo às fls. 131/139), 01 (um) aparelho televisor 31" da marca Buster, avaliado em R\$500,00 (quinhentos reais), e 02 (dois) maços de hastes em alumínio, avaliados em R\$200,00 (duzentos reais), pertencentes à "Escola Municipal Hide Maluf Junior", não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo a denúncia, aproveitando-se da vigilância atenuada pelo período de repouso noturno, Eduardo se dirigiu ao estabelecimento escolar para a prática de furto.

Após escalar o muro da escola e arrombar o portão de uma quadra, ingressou no imóvel e passou a se apoderar dos objetos acima descritos.

Ocorre que, no momento que extraía hastes de alumínio fixadas no imóvel, foi detido por policiais militares acionados ao local - o televisor já estava separado na parte externa (auto de fls. 21 e foto fls. 34).

Na Delegacia, ficou silente (fls. 08/09).

O crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu, quais sejam, a comunicação anônima à Polícia Militar e a pronta intervenção dos agentes policiais. Foi designada audiência para proposta de acordo de não persecução penal (fls. 83), porém, o réu não compareceu, por ter sido preso na mesma data (fls. 95).

Oferecida a denúncia, ela foi recebida (fls. 106/107), o réu citado (fls. 114), apresentando resposta escrita, na qual alegou que não há questões preliminares conhecidas no momento e as questões de mérito serão tratadas posteriormente (fls. 118/119).

O recebimento da denúncia foi mantido, designando-se audiência (fls. 120/122).

Durante a instrução, foram ouvidas a representante da vítima e 02 testemunhas comuns, sendo decretada a revelia do réu que, intimado, não compareceu em Juízo.

Encerrada a instrução, em memoriais, as partes se manifestaram.

É o relatório.

DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

1) Da materialidade

A materialidade delitativa está consubstanciada no auto de exibição e apreensão de fls. 21 e na fotografia de fls. 34.

2) Da autoria

A autoria criminosa é certa e deve ser atribuída ao réu.

Durante a fase policial, o réu permaneceu silente (fls. 08/09).

Na fase judicial, o réu não compareceu em Juízo, para ser interrogado.

A prova dos autos foi suficiente para a certeza da acusação. Vejamos.

A representante da vítima M.A.C.C. declarou que não trabalha na escola mencionada na denúncia, mas sim na Escola Melo Cotrin. Deve ter tido algum mal entendido, porque não tem relação com a outra escola mencionada na denúncia e nada sabe sobre os fatos. A escola é municipal e trabalha em escola estadual. Não sabe quem representa a escola em comento.

O policial militar Valdemir de Oliveira Machado asseverou que o Copom informou que havia um indivíduo dentro de uma escola. Foram até o local e encontraram o réu, que já tinha retirado uma TV da escola e umas hastes de alumínio que teriam sido retirados do local. Não se recorda se o réu estava dentro ou fora da escola. Ele tinha escondido a TV perto de uma árvore. Pegaram o réu dentro da escola. Ele tinha retirado a TV e tinha voltado para pegar o restante, quando foi encontrado. A porta da sala de aula estava arrombada. O réu confessou que tinha pegado a TV de dentro da escola. O réu escalou o muro, quebrou alguns offendículos, que eram as hastes,

depois arrombou uma porta de uma das salas, de onde retirou a TV. As hastes ficavam no muro da escola, fazendo a proteção. O diretor esteve no local e disse que as hastes faziam o alarme disparar. Não conhecia o réu, mas seu motorista o conhecia de outros furtos. Os fatos ocorreram de madrugada. A TV estava na calçada, fora da escola. Seu motorista era o Pazetti.

No mesmo sentido, o depoimento do também policial militar André da Silva Pazetti, segundo o qual estavam em patrulhamento próximos, quando o Copom os solicitou, porque a vizinha estava ouvindo alarmes da escola. Foram ao local e perceberam que o portão anexo à quadra estava aberto, por onde ingressaram. Entraram na escola e encontraram o réu num canto, enrolando as hastes do para-raios da escola. O réu disse que estava sozinho. Também perceberam que portas estavam arrombadas e a TV tinha sido retirada e colocada em local para ser subtraída. Para retirar o material, o réu teve que subir no telhado, para a retirada das hastes do para-raios. A TV estava no pavilhão de salas de aula, onde as portas estavam arrombadas. O réu confessou a prática do crime e a retirada das hastes e o arrombamento das portas. Não conhecia o réu. O portão da quadra estava sem cadeado. A porta arrombada era interna, da sala de aula. Quando chegaram, a TV estava fora das salas de aula, num canto, escondida, perto do réu.

Com efeito, a prova é suficiente para a certeza da autoria.

O réu, em solo policial, nada disse sobre os fatos. Judicialmente, o réu não compareceu para dar sua versão sobre os fatos.

Os policiais militares narraram que foram solicitados, pelo Copom, para averiguarem furto em andamento em escola municipal. André disse que constatarem o portão da quadra aberto e ingressaram por ele. Avistaram o réu dobrando barras de alumínio do para-raios e o abordaram. Encontraram, também, uma TV, já na parte externa da escola, no pátio ou na calçada. A TV tinha sido retirada de uma sala de aula que teve a porta arrombada.

Assim, ainda que o réu negue a autoria delitiva, o certo é que o réu foi flagrado pelos policiais militares no interior da escola, dobrando as hastes que pretendia subtrair, ou seja, em plena ação delitiva.

Por outro lado, ter sido o réu abordado na posse da res furtiva, já traz a certeza da acusação, cabendo ao próprio acusado a tarefa de afastar tal presunção.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Furto simples – Recurso defensivo – Absolvição – Fragilidade – Materialidade e autoria demonstradas – Apreensão da res em poder do acusado gera a presunção da autoria do delito, invertendo-se o ônus da prova – Pena reclusiva mantida – Dia-multa fixado no valor unitário mínimo legal – Regime inalterado dada a comprovada presença de antecedentes criminais – Inviável a substituição da pena corporal por restritivas de direitos – Ausência de recurso ministerial nesse sentido – Recurso parcialmente provido”. (TJSP - Apelação Criminal 0000318-78.2015.8.26.0544. Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Fernando Torres Garcia – j. 20/08/2020 - grifei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado pelo concurso de agentes – Sentença condenatória – Pleito absoluto inadmissível – Provas suficientes de materialidade e autoria delitiva – Réu que foi surpreendido na posse do produto furtado, sem explicação plausível – Prova oral suficiente para a condenação – (...)”. (TJSP - Apelação Criminal 1500587-42.2018.8.26.0575. Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto – j. 02/03/2021 - grifei)

“APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO – ARTIGO 155, § 1º e § 4º, inciso I, DO CÓDIGO PENAL – Subtração de diversos itens de vestuário do interior de estabelecimento comercial, mediante quebra da vidraça da loja, durante repouso noturno – Recurso defensivo que não questiona a autoria delitiva. Confissão. Apreensão em flagrância em posse da res. Ainda, palavras da vítima e dos servidores policiais seguras e consistentes. Condenação mantida – (...). RECURSO NÃO PROVIDO”. (TJSP - Apelação Criminal 1501430-28.2019.8.26.0201. Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): José Vitor Teixeira de Freitas – j. 28/02/2021 - grifei)

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. SIMULAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA E VIOLÊNCIA. CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. REFORMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO

PESSOAL EXTRAJUDICIAL. DEPOIMENTOS JUDICIAIS DE POLICIAIS MILITARES. VALIDADE. "RES" NA POSSE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVAS SUFICIENTES A CONVENCER DO DECRETO CONDENATÓRIO. CONSUMAÇÃO. A SIMPLES INVERSÃO DA POSSE DA COISA SUBTRAÍDA É O BASTANTE PARA A CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. INTELIGÊNCIA DO ART. 59, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA COMPROVADA. REGIME PRISIONAL FECHADO. PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO EM DESFAVOR DO RÉU. (...) 4. Encontro de parte da "res furtiva" em poder do agente, a lhe impor o ônus, do qual não se desincumbiu, de explicar tal posse, de início muito comprometedora, tanto mais ante o reconhecimento que a vítima realizou do indigitado agente. Inversão do ônus da prova. Precedentes do STF, "mutatis mutandis" (ARE 822.045/SC - Rel. Min. Roberto Barroso - j. 28.08.2014 - DJE 02.09.2014 e RE 731.662/SC - Rel. Min. Dias Toffoli - j. 22.05.2014 - DJE - 28.05.2014) e do STJ (ARE 329.535/PI - Rel. Min. Marilza Maynard - 6ªT. - DJE 25.08.2014 e HC 243.033/SP - Rel. Min. Jorge Mussi - 5ªT. - j. 19.11.13) e do TJSP (Ap. 0086071-98.2013.8.26.0050 - Rel. Des. Salles Abreu - j. 17.09.2014; Ap. 0010663-73.2011.8.6.0664 - Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalcheiro - j. 02.09.2014 e Ap. 0090615-03.2011.8.26.0050 - Rel. Des. Grassi Neto - j. 20.03.2014). (...) (TJSP; Apelação Criminal 0038485-65.2013.8.26.0050; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 11ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/11/2018; Data de Registro: 07/12/2018).

APELAÇÃO DAS DEFESAS. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE E PELO CONCURSO DE AGENTES. VALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.

"RES" ENCONTRADA EM PODER DOS RECORRENTES, O QUE EXIGE EXPLICAÇÃO SOBRE A POSSE ESPÚRIA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RÉUS CONFESSOS. TESTEMUNHOS DE AGENTES PÚBLICOS. VALIDADE. PRECEDENTES. QUALIFICADORAS DEMONSTRADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ESTELIONATO. "MUTATIO LIBELLI". FURTO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. REGIME ABERTO MANTIDO. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS. (...) 2. Materialidade e autorias comprovadas com relação ao crime de furto. Circunstâncias do caso concreto indicam o dolo adequado às espécies, sobretudo pelas provas orais, colhidas perante o contraditório, recepcionadas pelas demais provas dos autos. 3. Furto. Encontro da "res furtiva" em poder do agente, a lhe impor o ônus, do qual não se desincumbiu, de explicar tal posse, de início muito comprometedora. Precedentes do TJSP (Ap. 0000880-56.2011.8.26.0244 - 8ª C - Rel. Des. Alcides Malossi Junior - j. 23.02.2017 - DJe 23.02.2017; Ap. 0023445-74.2015.8.26.0405 - 3ª C - Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalcheiro - j. 14.02.2017 - DJe 14.02.2017; Ap. 0002534-30.2011.8.26.0357 - 8ª C - Rel. Des. Carlos Monnerat - j. 09.02.2017 - DJe 16.02.2017; Ap. 0002710-04.2014.8.26.0066 - 9ª C - Rel. Des. Souza Nery - j. 15.12.2016 - DJe 09.01.2017 e Ap. 3001436-92.2013.8.26.0484 - 8ª C - Rel. Des. Grassi Neto - j. 22.09.2016 - DJe 31.01.2017). (...) (TJSP; Apelação 0042098-25.2015.8.26.0050; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 8ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 10/04/2018; Data de Registro: 13/04/2018).

No caso dos autos, na fase policial, o réu não apresentou versão e, em Juízo, não apresentou versão, de forma que a presunção é certa.

A condenação, portanto, se impõe.

3) Da tentativa

A jurisprudência do Egrégio Tribunal Superior de Justiça adotou a teoria da apprehensio ou amotio, no sentido de que o furto de consuma com a posse do bem desde que se tenha cessado a clandestinidade.

Nesses termos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. DIREITO PENAL. FURTO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. LEADING CASE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 102.490/SP. ADOÇÃO DA TEORIA DA APPREHENSIO (OU AMOTIO).

PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Recurso especial processado sob o rito do art. 543-C, § 2º, do CPC e da Resolução n. 8/2008 do STJ. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto

quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. 3. Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos: Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença que condenou o recorrido pela prática do delito de furto consumado. (REsp 1524450/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 29/10/2015). Como o réu ingressou na escola, conseguiu retirar o aparelho televisor e as hastes, mas foi abordado pelos policiais ainda dentro da escola, não conseguiu fazer cessar a clandestinidade e deve ser reconhecida a figura tentada.

4) Das qualificadoras

Neste momento, cabe perquirir sobre as qualificadoras da escalada e de arrombamento do estabelecimento.

O laudo pericial do local de fls. 131/139, atestou a existência de duas portas no interior da escola, que se encontravam obstruídas com orientação dos danos de fora para dentro, compatíveis com arrombamento.

O laudo pericial também informou que o muro perto da quadra tinha altura de 1,70m, no entanto, o policial militar André informou que o portão da quadra estava aberto e, por lá ingressaram na escola.

Ora, se o portão estava aberto, o réu não precisou usar de habilidade para pular o muro.

Assim, a qualificadora da escalada deve ser afastada.

5) Do repouso noturno

O furto cometido durante o repouso noturno, assim reconhecido entre o período em que, naquela localidade onde os fatos ocorreram, a população costumeiramente se recolhe e desperta para a vida cotidiana, é apenado com maior rigor, uma vez que o bem jurídico tutelado está mais vulnerável.

No caso concreto, o réu praticou o delito em uma escola municipal, por volta das 02h40. Assim, o fato é que o horário era de menor atenção e a res estava menos protegida, por isso, a causa de aumento deve ser reconhecida.

Sobre o assunto, assim já se manifestou Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 15ª edição, Rio de Janeiro, Editora Forense, 2015, p. 876): "a causa de aumento está presente desde que a subtração ocorra durante o repouso noturno, ou seja, quando as pessoas de um modo geral estão menos atentas, com menor chance de vigilância dos seus e dos bens alheios, com ou sem moradores no seu interior repousando, o furto merece pena mais severa. É a solução correta, pois sustentar o contrário faz com que a circunstância agravante se concentre no fato de haver maior perigo para a vítima – que está em casa dormindo – quando a subtração se realiza no mesmo local, o que nos parece tenha sido o objetivo da lei. Nessa visão: STJ: "Para a incidência da causa especial de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal, é suficiente que a infração ocorra durante o repouso noturno, período de maior vulnerabilidade para as residências, lojas e veículos, sendo irrelevante o fato de que o crime tenha sido cometido em estabelecimento fechado" (REsp 1.191.065-MG, 5ª T., rel. Gilson Dipp, 17.04.2012, v.u.).

Assim já se manifestou o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

APELAÇÃO. (1) FURTO SIMPLES. REPOUSO NOTURNO MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.

(2) RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO PELA VÍTIMA. VALIDADE. (3) TESTEMUNHOS DE AGENTES PÚBLICOS. VALIDADE. (4) "RES" ENCONTRADA NA POSSE DO RECORRENTE, O QUE EXIGE EXPLICAÇÃO SOBRE A POSSE ESPÚRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. (5) RÉU

CONFESSO. (6) MANTIDA A CAUSA DE AUMENTO PELO REPOUSO NOTURNO (7) FURTO CONSUMADO.

(8) DOSIMETRIA DA PENA QUE EXIGE REPARO. CERTIDÕES INIDÔNEAS PARA EXASPERAR A PENA-BASE. CONTRADIÇÃO À SÚMULA 444, DO STJ. (9) DESDOBRAMENTO DA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA MERECEDORA DE REPARO, SOB O RISCO DE INTERPRETAÇÃO "IN MALAM PARTEM".

(10) REGIME SEMIABERTO. (11) DETRAÇÃO PENAL. NÃO CABIMENTO NESTA INSTÂNCIA. (12)

PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. (...) 6.2. Repouso noturno. Não se adota o critério do exato momento em que a vítima estaria dormindo, sob pena de incorrer em

demasiada subjetividade e gerar enorme insegurança jurídica. Aliás, o aumento de pena atinente ao repouso noturno justifica-se não somente pela menor intensidade de vigilância por parte da vítima, mas, mormente, em relação à vigilância dada por terceiros. Outrossim, não há que se falar sobre a necessidade do imóvel ser uma residência ou estabelecimento comercial, porquanto o local em que se deu o crime é irrelevante, bastando que ele seja praticado, tão somente, durante o período de repouso noturno. Precedentes do STJ (REsp 1113558/RS - Rel. Min. Jorge Mussi - 5ª T. - j. 17.06.2010 - DJe 28.06.2010 e HC 29.153/MS - Rel. Min. Gilson Dipp - 5ª T. - j. 02.10.2003 - DJe 03.11.2003). (...) 8. Provimento parcial do recurso defensivo. (TJSP - Relator(a): Airton Vieira; Comarca: Santo André; Órgão julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 22/11/2016; Data de registro: 24/11/2016).

Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça ensina:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. TENTATIVA DE FURTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, CONDUTA SOCIAL, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO GENÉRICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DELITO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 155, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. FURTO QUALIFICADO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO EM